

1513627-94.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2155614/2020 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 12108308 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 58/20/104 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2155614 - 04º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1513627-94.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513627-94.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2155614/2020 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 12108308 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 58/20/104 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2155614 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RAFAEL GONCALVES PEREIRA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

LUCAS RAFAEL GONÇALVES PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/04), no dia 26 de junho de 2020, por volta das 08h30, na Alameda Barão de Piracicaba, nº 139, Santa Cecília, nesta capital de São Paulo, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879), trazia consigo e transportava

para a entrega ao consumo de terceiros, 63 (sessenta e três) papelotes contendo maconha, 127 (cento e vinte e sete) papelotes contendo cocaína e 12 (doze) tubos de plástico contendo skank, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta da denúncia que segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento motorizado pela região conhecida como Cracolândia, quando avistaram o denunciado caminhando pela via pública com uma mochila de cor azul nas costas, em direção ao local destinado ao consumo de drogas. Ao notar a presença policial, o denunciado passou a agir de forma suspeita, eis que se mostrou nervoso com a aproximação dos milicianos, que deliberaram pela abordagem.

Relata a inicial que na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, em revista no interior da mochila de LUCAS, os policiais localizaram os entorpecentes acima citados, assim distribuídos: 63 (sessenta e três) papelotes contendo maconha, 127 (cento e vinte e sete) papelotes contendo cocaína, e 12 (doze) potes plástico contendo skank, além de sujidades de tetrahydrocannabinol (THC) (conforme auto de exibição/apreensão de fl. 17).

Narra a exordial que indagado, o denunciado confessou a mercancia, afirmando que estava realizando o transporte das drogas a serviço de outro indivíduo e que receberia entorpecentes como forma pagamento.

Segundo a acusação, em solo policial, modificou sua versão, alegando desconhecimento quanto ao conteúdo da mochila, afirmando tê-la recebido de terceiro desconhecido, o qual lhe deu três pedras de crack como pagamento, que foram imediatamente consumidas (fls. 08).

Expõe a denúncia que o laudo de constatação de fls. 20/24 e o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 74/76, restaram positivo para 80 gramas de tetrahydrocannabinol (THC), 73,2 gramas de cocaína e 8 gramas de tetrahydrocannabinol (THC).

Ao fim, é da inicial acusatória que a quantidade de drogas que o denunciado trazia consigo e transportava, bem como a forma como se achavam acondicionadas, além do local em que o denunciado foi abordado, são circunstâncias que demonstram que as drogas se destinavam ao tráfico.

Por decisão exarada em 27 de junho de 2020, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fundamento no disposto pelos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 62/64).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 14 de julho de 2020 (fls. 86/87).

Nesta mesma data, a prisão preventiva outrora decretada em desfavor do acusado foi revogada (fls. 90/91).

O acusado não foi encontrado no endereço fornecido para citação (fls. 121/124). Por esta razão, o Ministério Público requereu o restabelecimento da prisão preventiva em desfavor do acusado (fl. 127).

Aos 08 de abril de 2021, foi suspenso o processo e o prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 129/131).

Posteriormente, o réu foi citado, pela ferramenta Teams, junto ao CDP Belém II (fl. 143).

Na sequência, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 147).

Na data de 29 de setembro de 2021, o recebimento da denúncia foi mantido e, na mesma ocasião, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 30 de maio de 2022 (fls. 169/170).

O acusado foi intimado a comparecer à audiência supra designada (fl. 187).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois o réu é primário, confesso, sem antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são

amplamente favoráveis; b) o afastamento da agravante mencionada na denúncia (art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal), uma vez que o estado de calamidade decretado em virtude da pandemia em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito, devendo existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento jurídico; c) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante da primariedade do réu e da ausência de comprovação de que se dedique ao tráfico ou de que faça parte de organizações criminosas para o mesmo fim, estando presentes, portanto, todos os requisitos legais; d) a outorga de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da culpabilidade em tese atenuada do acusado e considerando que a mera gravidade em abstrato do delito não implica, necessariamente, em tratamento penal mais rigoroso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores; e) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor. Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 05), Boletim de ocorrência (fls. 13/16), Auto de exibição e apreensão (fl. 17), Fotografia dos entorpecentes apreendidos (fl. 18), Laudo de constatação (fls. 20/24), Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 74/76), Relatório final de inquérito policial (fls. 77/79), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o Laudo de Exame Químico-Toxicológico nº 204905/2020 (fls. 74/76) revelou resultado positivo para as substâncias tetrahydrocannabinol (Itens 1 e 3), bem como cocaína (Item 2)

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Rogério Batista Barbosa, policial militar, expôs, em síntese, que estavam no patrulhamento de rotina quando visualizaram o réu. Tem uma hora que é feita limpeza e ocorre um trânsito de pessoas. Não se recorda onde estavam as drogas, se em sacola ou nas vestes. A equipe já prendeu o réu por tráfico de drogas duas vezes, na cracolândia, em ruas diferentes e datas diferentes. Infelizmente ele estava nessa situação, transportando drogas. A diferenciação é a quantidade e ao avistar a viatura eles se demonstram muito nervosos. Infelizmente os traficantes se aproveitam da situação de quem é usuário e utilizam essas pessoas para transportar as drogas para eles. O usuário normal não vai estar com essa quantidade. O depoente era motorista da viatura. Não se recorda se houve a apreensão de dinheiro. Não se recorda se o réu declarou alguma coisa na ocasião.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Ana Paula Teixeira, policial militar, que relatou, em síntese, que estavam patrulhando, avistaram o réu carregando uma mochila nas costas. Ao visualizar a viatura o réu acelerou os passos e isso motivou a abordagem. Abordaram o réu e realizada busca pessoal. Ao verificar a mochila foi encontrada maconha, cocaína e skunk. O réu falou que estava levando a mando de outra pessoa para a cracolândia e não sabia dizer o nome.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Em suma, o réu aduziu que está com 23 anos de idade. Está preso por furto desde 1º de dezembro de 2021, pena 1 ano e 2 meses. Estava na situação de morador de rua há nove anos. Era menor de idade e já estava na situação de rua. Pelo que sabe o pai se matou e a mãe fugiu para outra cidade, não se recordando a idade que tinha, mas era criança. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Estava na cracolândia onde foi buscar

duas pedras de crack e acabou se deparando com conhecido, também usuário, ele estava com uma mochila na mão e pediu para levar a mochila até do outro lado da avenida. Pelo fato de ser usuário de crack recebeu duas pedras de crack para transportar a mochila. A pessoa não disse para quem deveria entregar, só disse que a pessoa iria aparecer. Sabia que tinha droga na mochila. Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza e variedade das drogas apreendidas (maconha, cocaína e skank); b) pela considerável quantidade de drogas (161,2g no total), incompatível com a condição de mero usuário; c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas; d) pelas circunstâncias e pelo local da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo e transportava as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal

No tocante à agravante de ter o agente cometido o crime em ocasião de calamidade pública, em que pese o Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020 ter reconhecido a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em virtude da atual pandemia ocasionada pelo coronavírus (COVID-19), in casu, não restou demonstrado que o agente tenha se aproveitado da situação para a prática do crime de tráfico de drogas, ausente prova de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta praticada pelo réu.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado da 12ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"O decreto de estado de calamidade pelo Governo Federal em razão da pandemia do

novo coronavírus Covid19 não autoriza automaticamente o reconhecimento da referida agravante a todos os crimes praticados enquanto perdurar a calamidade. Necessária a existência de relação do tráfico com o estado de calamidade, valendo-se, por exemplo, o agente das facilidades que dela decorrer, que garanta a impunidade ou que o beneficie, de qualquer forma, o que não se revela nos autos.” (Apelação Criminal nº 1514467-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Paulo Rossi, 23 de março de 2021) (grifos nossos)

No mesmo sentido: Apelação Criminal 1509934-05.2020.8.26.0228 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Sérgio Mazina Martins, de 14 de outubro de 2021, e Habeas Corpus nº 629867/SP do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, de 01 de fevereiro de 2021.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase verifico que o réu é primário e não ostenta antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base, conforme se infere da folha de antecedentes as fls. 47/48 e certidão as fls. 49/50. No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena prevista no preceito secundário do caput do artigo 33. Sendo assim, aplicando a causa de diminuição já mencionada, reduzo a pena base de 2/3 (dois terços), chegando ao resultado de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

“(…) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (…”. (grifos nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

“(…) Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade.

Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de

circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos)

Da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado LUCAS RAFAEL GONÇALVES PEREIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 166 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA